

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음1) 판사 A가 항소심 재판부의 구성원으로 참여하는 것이 민사소송법상 제척사유인 `법관이 사건에 관하여 직무상 관여한 전심재판`에 해당하는지 여부를 근거와 함께 논하시오.》

<문제3.2의 물음1> 법관이 제1심 판결 후 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것이 전심판여 제척사유에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 제1심에서 원고 승소판결을 선고한 판사 A가 인사이동으로 동일 사건의 항소심 재판부 구성원이 되어 심리에 관여하게 된 상황이다. 쟁점으로 <제1심 판결을 담당한 법관이 항소심 재판부에 참여하는 것이 민사소송법상 전심재판에 직무상 관여한 경우에 대하여 제척사유가 되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 A의 항소심 관여가 전심재판 관여를 이유로 한 제척사유에 해당하는지 논한다.

II. 법관의 제척사유와 전심판여

1. 제척제도의 의의 및 취지

- 제척은 법관이 구체적인 사건과 특수한 관계에 있어 재판의 공정성을 기대하기 어렵다고 판단되는 경우, 법률이 정한 객관적 사유에 기해 당연히 직무집행을 배제하는 제도다. 이는 재판의 공정성에 대한 외관상의 신뢰를 확보하고 불공정한 재판을 사전에 방지하는 데 목적이 있다.

2. 전심판여의 요건

- "민사소송법 제41조 제5호"에 따른 제척이 성립하기 위해서는 다음의 요건을 충족해야 한다.

(1) 전심재판의 존재

- 전심재판이란 상급심의 심판 대상이 된 하급심의 재판을 의미한다. 즉, 항소심의 입장에서 제1심 재판은 전심재판이 된다.

(2) 직무상 관여

- 법관이 전심재판의 최종 판단인 판결의 성립이나, 그 기초가 되는 사실인정 및 법률판단에 실질적으로 관여했어야 한다.

(3) 사건의 동일성

- 당해 사건과 전심 사건이 동일한 사건이어야 한다. 사건번호가 다르더라도 실질적으로 동일한 분쟁을 다루는 경우라면 이에 해당한다.

III. 전심판여의 구체적 판단 기준

1. 판례의 태도

- "대법원"은 제척사유인 전심판여를 엄격하게 해석한다. "판례"는 최종변론과 판결의 합의에 관여하거나 종국 판결과 더불어 상급심의 판단을 받는 중간적인 재판에 관여함을 말하는 것이고, 최종변론 전의 변론, 증거조가, 기일지정과 같은 소송 지휘상의 재판 등에 관여한 경우는 포함되지 않는다고 판시한다.

2. 심급의 이익 보호

- 전심재판에 관여한 법관이 상급심 재판에 다시 참여하게 되면, 자신이 내린 선행 재판을 스스로 번복하기 어려울 것이라는 심리적 편견이 작용할 수 있다. 이는 당사자가 가지는 심급의 이익을 침해할 우려가 크므로, 헌법상 보장된 공정한 재판을 받을 권리를 보호하기 위해 이를 금지하는 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 판사 A의 지위와 전심재판

- 사안에서 판사 A는 당해 사건의 제1심 판결을 담당하여 甲의 승소 판결을 직접 선고하였다. 이는 항소심의 심판 대상이 되는 전심재판에 해당하며, 판사 A는 판결의 핵심인 합의와 선고에 모두 참여한 자로서 실질적인 직무상 관여가 인정된다.

2. 제척사유의 성립 여부

- 항소심은 제1심의 당부를 판단하는 절차다. 판사 A가 항소심 재판부의 일원으로 참여하게 된다면, 乙이 제기한 항소 이유를 객관적으로 검토하기보다는 자신이 내린 제1심 판결의 정당성을 유지하려는 경향을 보일 가능성이 매우 높다. 이는 "민사소송법 제41조 제5호"가 금지하는 전형적인 전심판여의 사례다. 비록 정기 인사발령이라는 적법한 행정적 절차에 의해 항소심 재판부로 배속되었다 하더라도, 법관 개인의 신상 변화가 법률상 규정된 제척사유의 발생을 막지는 못한다.

V. 결론

- 판사 A는 제1심 판결이라는 전심재판에 실질적으로 관여한 법관이므로, 동일 사건의 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것은 "민사소송법 제41조 제5호"의 제척사유에 해당한다. 따라서 판사 A는 해당 항소심 사건의 직무집행에서 당연히 배제되어야 하며, 만약 판사 A가 참여한 상태에서 항소심 판결이 내려진다면 이는 절대적 상고이유인 판결 관여 불능 판사의 관여에 해당하여 파기 사유가 된다.